DATOS DEL PROCESO ARBITRAL

NRO. DE EXPEDIENTE : EXP. NRO. 03-2022-JALR-CECARD/AYA.

MODALIDAD DE ARBITRAJE : Arbitraje Ordinario.

PARTES INTERVINIENTES :

Demandante : Consorcio Astor

Demandado : Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A – SEDA AYACUCHO

TRIBUNAL UNIPERSONAL : Abg. José Antonio León Rodríguez – Árbitro Único.

SECRETARIA ARBITRAL : Abg. Raida Yovana Flores Cayllahui.

MATERIA DE CONTROVERSIA : Ampliación de plazo contractual y otros.

FECHA DE SOLICITUD : 08 de abril de 2022.

FECHA DE INSTALACION : 17 de mayo de 2022.

FECHA DE EMISION DE LAUDO : 20 de febrero de 2023.

ESCRITOS POST LAUDO : -

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

LAUDO DE DERECHO

Laudo de Derecho que en la controversia surgida entre el Consorcio Astor con el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho dicta el Árbitro Único José Antonio León Rodríguez.

Número de Expediente de Instalación: N° 03-2022-JALR-CA-CECARD/AYA.

Demandante: Consorcio Astor *(en lo sucesivo el CONTRATISTA, el CONSORCIO o el DEMANDANTE)*

Demandada: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho – Seda Ayacucho *(en lo sucesivo la ENTIDAD, SEDA-AYACUCHO o la DEMANDADA)*

Contrato: Contrato N° 033-2021-SEDA-AYACUCHO/G.G "Adquisición de Accesorios en H°D°, F°F° y otros para Seda Ayacucho"

Monto del Contrato: S/. 249,567.10 Soles.

Cuantía de la Controversia: S/. 24.956.71 Soles como pretensiones determinadas y dos pretensiones indeterminadas.

Tipo y Número de Proceso de Selección: Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 10-2021-SEDA AYACUCHO-2.

Árbitro Único: José Antonio León Rodríguez.

Secretaría Arbitral: Raida Yovana Flores Cayllahui – Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD.

Monto de los honorarios del Árbitro Único: S/. 3,150.00 Soles.

Monto de los gastos administrativos: S/. 2,250.00 Soles.

Fecha de emisión del laudo: 20 de febrero de 2023

N° de Folios: 37

Pretensiones (controversias relacionadas a las siguientes materias):

☐ Nulidad, invalidez, inexistencia y/o ineficacia del contrato.
☐ Resolución del contrato.
X **Ampliación del plazo contractual**
☐Defectos o vicios ocultos.
☐Formulación, aprobación o valorización de metrados.
☐Recepción y conformidad.
☐ Liquidación y pago.
☐ Mayores gastos generales.
☐ Indemnización por daños y perjuicios.
☐ Enriquecimiento sin causa.
☐Adicionales y reducciones.
☐Adelantos.
X **Penalidades.**
☐ Ejecución de Garantías.

INDICE

I. ANTECEDENTES…….. ……..……..……...…4

II. LO ACTUADO EN EL PROCESO ARBITRAL……..……..……...…5

III. COSTOS DEL PROCESO……..……..……...…8

IV. DECLARACIONES PRELIMINARES……...……..……...…9

V. NORMAS APLICABLES……..……...…9

VI. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA……..……..……...…10

VII. LAUDO……..……..……...…37

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

RESOLUCIÓN N° 18:

En la ciudad de Ayacucho, a los 20 días del mes de febrero de 2023, realizadas las actuaciones arbitrales de conformidad con la ley y las normas establecidas por las partes, escuchados los argumentos del demandante y del demandado, el Árbitro Único dicta el presente Laudo de Derecho.

I. ANTECEDENTES

1.1 El 23 de diciembre de 2021, las partes suscribieron el Contrato N° 033-2021-SEDA-AYACUCHO/G.G "Adquisición de Accesorios en H°D°, F°F° y otros para Seda Ayacucho".

1.2 La Cláusula Décima Sétima del Contrato dispone que:

> "***Solución de Controversias***
> *Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.*
> *Cualquiera de las partes tiene el derecho de iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.*
> *Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato sólo pueden ser sometidas a arbitraje.*
> *El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado".*

1.3 Con fecha 17 de mayo de 2022, en la sede institucional del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD con la participación del Árbitro Único y la Secretaria Arbitral, se expidió la Resolución N° 01, con la cual se formalizó la instalación del proceso arbitral. En ese mismo acto el Árbitro Único ratificó su aceptación, señalando que no tiene ninguna incompatibilidad ni compromiso alguno con las partes, obligándose a desempeñar con imparcialidad y probidad la labor encomendada; expresando su conformidad con la designación realizada, y manifestando que, al momento de la expedición de la referida resolución, no tiene conocimiento de alguna causa que pudiera motivar una recusación.

1.4 Asimismo, en la referida Resolución N° 01, a la cual en lo sucesivo nos referiremos como el "Acta de Instalación", el Árbitro Único fijó las reglas de este arbitraje estableciendo que es uno Institucional, Nacional y de Derecho.

1.5 Así también, el Árbitro Único encargó la Secretaría del proceso a la abogada Rosnery Gladis Dominguez Quispe, estableciendo que la presentación de todo escrito y/o comunicación de las partes debía ser remitido de manera virtual al correo institucional mesadepartesdearbitraje.cecard@gmail.com, en el horario de 8:00 am a 6:30 pm.

II. LO ACTUADO EN EL PROCESO ARBITRAL.

2.1 El 28 de junio de 2022, el **CONTRATISTA** presentó el escrito de su demanda, solicitando el reconocimiento de sus pretensiones para lo cual ofreció los medios probatorios que detalló y adjuntó al mismo.

2.2 Mediante Resolución N° 04 de fecha 04 de julio de 2022, se dispuso admitir a trámite la demanda interpuesta por el **CONTRATISTA**, teniendo por ofrecidos sus medios probatorios, corriéndose traslado de la misma a la **ENTIDAD** para que en el plazo de diez (10) días hábiles presente su contestación a la demanda y, de considerarlo conveniente, formule en el mismo acto reconvención; ofreciendo los medios probatorios que respalden su posición.

2.3 De igual forma, en dicha resolución se resolvió tener por cancelados los costos arbitrales correspondientes al **CONTRATISTA** y a la **ENTIDAD** que fueron determinados en el Acta de Instalación; y asimismo, por cumplido el registro en el SEACE por parte de **SEDA-AYACUCHO**.

2.4 Con fecha 19 de julio de 2022, la **ENTIDAD** presentó la contestación a la demanda, para lo cual ofreció los medios probatorios que detalló y adjuntó al mismo.

2.5 Mediante Resolución N° 05 del 22 de julio de 2022, se resolvió admitir a trámite la contestación de la demanda presentada por la **ENTIDAD**; y se resolvió ponerla en conocimiento del **CONSORCIO** para los fines que estime conveniente.

2.6 Con fecha 10 de agosto de 2022, se expidió la Resolución N° 06, en la cual se determinaron los puntos controvertidos del presente proceso arbitral y se admitieron los medios probatorios ofrecidos por las partes. Los puntos materia de la controversia fueron los siguientes:

> *"1. Determinar si corresponde que el Tribunal Arbitral declare procedente la solicitud de ampliación de plazo para la ejecución del Contrato N° 033-2021-SEDA-AYACUCHO/G.G. de fecha 23 de diciembre de 2021.*
> *2. Determinar si, subordinamente al primer punto controvertido, corresponde que el Tribunal Arbitral declare como justificado el retraso del CONSORCIO ASTOR en la ejecución del contrato 033-2021-SEDA-AYACUHCO/G.G. de fecha 23 de diciembre de 2021.*
> *3. Determinar, sí corresponde que el que el Tribunal Arbitral ordene al SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO*

S.A. – SEDA AYACUCHO realizar la devolución del monto de la carta Fianza por concepto de Garantía de Fiel Cumplimiento, por el monto total de S/ 24.956.71 soles a favor del CONSORCIO ASTOR.
4. Determinar si corresponde que el Tribunal Arbitral ordene a la SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A. – SEDA AYACUCHO realizar el pago de todos los gastos arbitrales, costas y costos y demás gastos que se generen del presente proceso."

2.7 De igual forma, en la misma resolución se resolvió admitir los medios probatorios presentados por el **CONSORCIO** con fecha 28 de junio de 2022, los cuales son los mismos ofrecidos por la **ENTIDAD**; y se le concedió a las partes el plazo de cinco (05) días hábiles para que expresen lo conveniente a su derecho respecto de los puntos controvertidos fijados en la citada resolución.

2.8 Mediante escrito del 16 de agosto de 2022, el **CONSORCIO** formulo observación a los puntos controvertidos fijados en la Resolución N° 06; y mediante escritos del 18 de agosto de 2022, la **ENTIDAD** formuló observaciones sobre los puntos controvertidos y asimismo, precisiones a la contestación de la demanda que había presentado con fecha 19 de julio de 2022.

2.9 El 25 de agosto de 2022, se expidió la Resolución N° 07, en la cual se resolvió tener por admitidas las modificaciones propuestas por el **DEMANDANTE** en los puntos controvertidos primero y tercero:

"1. Determinar si corresponde que el Tribunal Arbitral declare procedente la solicitud de ampliación de plazo para la ejecución del Contrato N° 033-2021-SEDA-AYACUCHO/G.G. de fecha 23 de diciembre de 2021, peticionado mediante carta N° 002-2022/CONSORCIOASTOR/RC.
*3. Determinar, si corresponde que el que el Tribunal Arbitral ordene al SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A. – SEDA AYACUCHO devolver la suma de S/ 24.956.71 (Veinticuatro mil novecientos cincuenta y seis con 71/100 soles) a favor del CONSORCIO ASTOR, monto deducido en su pago final, por concepto de penalidad por mora***."**

De igual forma, se resolvió admitir como medio probatorio la Carta N° 002-2022/CONSORCIOASTOR-RC presentada por el **DEMANDANTE** y se resolvió correr traslado de la misma a **SEDA-AYACUCHO** por el término de cinco días hábiles para que exprese lo conveniente a su derecho.

2.10 Con fecha 07de setiembre de 2022, la **ENTIDAD** expresó sus argumentos respecto de las modificaciones propuestas por el **CONSORCIO** al primer y tercer punto controvertido. De igual forma, el **DEMANDANTE** el 08 de setiembre de 2022 absolvió el traslado a los escritos presentados por **SEDA AYACUCHO** mediante escritos del 18 de agosto de 2022.

2.11 Mediante Resolución N° 08 del 14 de setiembre de 2022, se resolvió reliquidar los honorarios y gastos arbitrales fijados, en virtud de que en el curso del proceso arbitral se han formulado tres pretensiones de cuantía indeterminada y una pretensión de cuantía determinada. En tal sentido, se les otorgó a las partes el plazo de diez (10) días hábiles para que cumplan con el pago ordenado.

2.12 Con fecha 14 de setiembre de 2022 se expide la Resolución N° 09, la cual resuelve declarar la etapa probatoria del proceso arbitral, se les otorgó a las partes el plazo de cinco (05) días hábiles para que presenten sus alegatos por escrito y se les cito a la Audiencia de Informes Orales para el día lunes 10 de octubre a las 11:00am.

2.13 El 23 de setiembre de 2022, las partes presentaron sus escritos de alegatos. En razón de ello, mediante Resolución N° 10 del 27 de setiembre de 2022, se resolvió poner en conocimiento de su contraparte, los escritos presentados por el **CONSORCIO** y por **SEDA AYACUCHO**.

2.14 El 10 de octubre de 2022 se llevó a cabo la Audiencia de Informes Orales con la presencia del **CONSORCIO** y de la **ENTIDAD**. En dicha Audiencia se concedió el uso de la palabra al **DEMANDANTE** y a la **DEMANDADA** por espacio de diez minutos para que manifieste lo conveniente a su derecho.

2.15 Mediante Resolución N° 11 del 06 de octubre de 2022, se comunica a las partes que la Secretaria Arbitral será asumida por la doctora Raida Yovana Flores Cayllahui.

2.16 Con fecha 14 de octubre de 2022 se expidió la Resolución N° 12, en la cual se resolvió otorgar a las partes un plazo excepcional de cinco (05) días hábiles para que cumplan y/o acrediten el pago de los honorarios arbitrales establecidos en la Resolución N° 08. El 17 de octubre de 2022, el **CONSORCIO** presentó como medios probatorios las guías de remisión presentadas a la **ENTIDAD**; y en la misma fecha, la **DEMANDADA** presentó medios probatorio excepcionales, a fin de que sean merituados por el Árbitro Único.

2.17 Mediante Resolución N° 13 del 25 de octubre de 2022 se dispuso suspender el proceso arbitral por el plazo de veinte (20) días hábiles en atención al incumplimiento de las partes en acreditar y/o cumplir con el pago de los honorarios y gastos arbitrales antes mencionados.

2.18 El 15 de noviembre de 2022 se expidió la Resolución N° 14, la cual resolvió levantar la suspensión del proceso arbitral, tener por cumplido el pago de los honorarios arbitrales y gastos administrativos que le correspondían asumir al **CONSORCIO**; y, asimismo, tener por cumplido el pago de los honorarios arbitrales que le correspondían asumir a la **ENTIDAD**. De igual forma, se dispuso facultar al **CONSORCIO** para que cancele los gastos administrativos que le corresponden asumir a la **DEMANDADA**. Con fecha 13 de diciembre de 2022 se emitió la Resolución N° 15, la cual resolvió suspender nuevamente el proceso arbitral, en atención a que el

DEMANDANTE no había cumplido con cancelar los gastos administrativos subrogados.

2.19 Mediante Resolución N° 16 del 29 de diciembre de 2022 se resolvió levantar la suspensión del proceso arbitral y tener por cumplido el pago de la reliquidación de los gastos administrativos efectuados por el **CONSORCIO**. Asimismo, se dispuso correr traslado del escrito presentado por el **DEMANDANTE** a **SEDA AYACUCHO** con fecha 17 de octubre de 2022, por el plazo de cinco (05) días hábiles, a fin de que se pronuncie en lo que considere pertinente; y de igual forma, se le corrió traslado con el escrito presentado por la **ENTIDAD** de fecha 17 de octubre de 2022 al **CONSORCIO** para que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifieste lo conveniente a su derecho.

2.20 Con fecha 05 de enero de 2023, el **CONSORCIO** absuelve el traslado formulado con la Resolución N° 16. Mediante Resolución N° 17 del 11 de enero de 2023 se dispuso fijar el plazo para laudar en treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la citada resolución, el cual podrá prorrogarse por quince (15) días hábiles adicionales.

III. COSTOS DEL PROCESO.

3.1 En lo referente a los costos arbitrales, estos fueron fijados en el Acta de Instalación del 17 de mayo de 2022 en la suma neta de S/. 2,100.00 Soles para la Árbitro Único y en S/. 1,500.00 Soles por concepto de gastos administrativos. Asimismo, mediante Resolución N° 08 del 14 de setiembre de 2022 se resolvió fijar un nuevo anticipo en la suma de S/.1,050.00 Soles para el Árbitro Único y en S/.750.00 Soles por concepto de gastos administrativos.

3.2 De la revisión del expediente arbitral y de los escritos presentados por las partes, se ha acreditado que el **CONTRATISTA** y la **ENTIDAD** han cumplido con la cancelar la totalidad de los honorarios y gastos arbitrales que le corresponden al Árbitro Único y a la Secretaría Arbitral.

IV. DECLARACIONES PRELIMINARES.

4.1 Antes de analizar la materia controvertida, corresponde remarcar lo siguiente:

(i) El Árbitro Único se ha instalado de conformidad con las normas que regulan la contratación estatal y con la conformidad de las partes.

(ii) En ningún momento se han impugnado o formulado reclamo alguno contra las disposiciones del proceso dispuestas en el Acta de Instalación.

(iii) El **CONTRATISTA** interpuso su demanda dentro del plazo previsto, ofreciendo las pruebas correspondientes.

(iv) La **ENTIDAD** fue debidamente emplazada con la demanda y ejerció plenamente su derecho de defensa, habiéndola contestado oportunamente.

(v) Las partes han tenido plena oportunidad y amplitud para ofrecer y actuar las pruebas aportadas al proceso.

(vi) Las partes no han presentado objeción o reclamo alguno por alguna vulneración al debido proceso o limitación al derecho de defensa.

(vii) Las partes han presentado sus alegatos y han tenido la oportunidad de informar oralmente sus argumentos.

(viii) El presente Laudo de Derecho se emite dentro del plazo previsto en el Acta de Instalación.

V. NORMAS APLICABLES.

5.1 En la Cláusula Décimo Sexta del Contrato se dispone que las normas aplicables son la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable; y, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

VI. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA.

De conformidad con la determinación de las cuestiones materia de pronunciamiento y admisión de medios probatorios, el Árbitro Único analizará la materia controvertida, en base a los puntos controvertidos fijados en la resolución respectiva.

En aplicación del Principio de Comunidad de la Prueba, las pruebas ofrecidas por las partes, desde el momento que fueron presentadas y admitidas como medios probatorios, pasaron a pertenecer al presente arbitraje, y, por consiguiente, pueden ser utilizadas para acreditar hechos que incluso vayan en contra de los intereses de la parte que las ofreció.

Al emitir el presente Laudo, el Árbitro Único, ha valorado la totalidad de los medios probatorios ofrecidos y admitidos a trámite en el arbitraje. De este modo, la no indicación expresa a alguno de los medios probatorios obrantes en autos o hechos relatados por las partes, no implica bajo ninguna circunstancia que determinado medio probatorio o determinado hecho no haya sido valorado. Por lo expuesto, el Árbitro Único deja establecido que en aquellos supuestos en los que este Laudo Arbitral hace referencia a algún medio probatorio o hecho en particular, lo hace

atendiendo a su estrecha vinculación, trascendencia, utilidad y pertinencia a criterio del Árbitro Único tuviese respecto de la controversia materia de análisis.

Asimismo, se deberá tener en consideración que la enumeración de los puntos controvertidos sobre los que se pronunciará el Árbitro Único es meramente ilustrativa, constituyendo una pauta referencial, la cual no limita el orden del análisis que realizará el Árbitro Único, respecto de la controversia y las pretensiones planteadas en el arbitraje.

Primer Punto Controvertido
"Determinar si corresponde que el Tribunal Arbitral declare procedente la solicitud de ampliación de plazo para la ejecución del Contrato N° 033-2021-SEDA-AYACUCHO/G.G. de fecha 23 de diciembre de 2021, peticionado mediante carta N° 002-2022/CONSORCIOASTOR/RC."

Posición del CONTRATISTA:

6.1 Con fecha 16 de noviembre de 2021, la **ENTIDAD** convocó al Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 10-2021-SEDA AYACUCHO-2, a fin de seleccionar a la firma contratista para la adquisición de Accesorios en HD en FF y otros para SEDA-AYACUCHO. Así el 26 de noviembre de 2021, se adjudica la buena pro y se procede firmar el Contrato N° 033-2021-SEDA-AYACUCHO/G.G.

6.2 En la cláusula quinta del referido Contrato se estableció que el plazo de ejecución era de 25 días calendarios, computados desde el día siguiente de la suscripción del contrato; es decir, a partir del 23 de diciembre de 2021.

6.3 En los primeros días de enero de 2022, el Ministerio de Salud, declaró oficialmente la tercera ola del Covid-19, ello debido a la presencia de la variante Ómicron, anunciando nuevas medidas para paliar el avance del virus. Es así que, el 06 de enero de 2022, se publica el Decreto Supremo N° 002-2022-PCM, la cual modificó el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM que declaró el Estado de Emergencia a consecuencia de la COVID-19 y estableció las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social, según el nivel de alerta en el que se encuentren. Con la referida modificatoria, se considera a Lima y a la Provincia Constitucional del Callao en el Nivel de Alerta Alto, lo que suponía una serie de restricciones, tales como la inmovilización social obligatoria desde las 23:00 horas hasta las 4:00 horas del día siguiente. Asimismo, se restringieron el aforo de las personas en los lugares concurridos por las personas.

6.4 Asimismo, para las ciudades considerados como el nivel de alerta Alto (como en el caso de Lima) se restringió el aforo al 50% de su capacidad en las tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias. Al respecto, también se vieron afectados los centros de producción, quienes tuvieron que reducir el número de

trabajadores, ello con la finalidad de evitarse la propagación del COVID – 19.

6.5 Ahora, como es sabido, la tercera ola fue generada a causa de la variante Ómicron, la cual se caracteriza por una alta contagiosidad, razón por la que se mostró un avance desmesurado de contagios en el Perú, lo que obligó a que el Gobierno Central adoptar medidas a fin de mitigar el avance de este virus, siendo, uno de ellos, la reducción de los aforos en las empresas, entre ellas, FUMOSAC.

6.6 En nuestro país, de acuerdo a los datos publicados por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, del 07 al 14 de enero de 2022, se reportaron 49,745 casos confirmados de COVID-19 y, del 14 al 21 de enero de 2022, se reportaron 54,696 casos confirmados de COVID-19, lo que demuestra el alto nivel de contagios de esta enfermedad.

6.7 Para el caso concreto, se tiene que la empresa Fundición Moreno S.A.C., cuya marca fue ofertada por nuestra parte en el Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 010-2021-SEDA AYACUCHO-2, mediante Carta N° 001-2022/FUMOSAC, nos comunicó "… *que por motivos de inventario no tuvimos producción la última semana de diciembre, además le informamos que venimos laborando en la actualidad con un 50% de personal por la pandemia del COVID-19, todo esto con la finalidad de evitar la propagación de COVID-19, en mérito a R.M. N° 1275-2020-MINSA… asimismo en nuestra empresa Fundición Moreno SAC también se presentaron más casos positivos de COVID-19, afectando el avance de la producción*".

6.8 Ante tal evento, a través de la Carta N° 001-2022/CONSORCIOASTOR-RC de fecha 13 de enero de 2022, solicitamos a la **ENTIDAD** la ampliación de plazo para la entrega de los bienes. Ante ello, el área usuaria, mediante Informe N° 011-2022-SEDE AYACUCHO-GO/DM, de fecha 20 de enero de 2022, declara procedente nuestra solicitud y nos otorga una ampliación de plazo por el término de 34 días calendarios.

6.9 Pese a la opinión favorable del área usuaria, la **ENTIDAD**, mediante Carta N° 004-2022-SEDA AYACUCHO- GAF-DLSG/ESPEJEC., nos notifica la Resolución Gerencial General N° 012-2022-SEDA AYACUCHO/GG, declarando improcedente nuestra solicitud de ampliación de plazo, ello debido a que nuestra parte no cumplió con cuantificar los días a solicitar.

6.10 Considerando la respuesta de la **ENTIDAD**, mediante Carta N° 002-2022/CONSORCIOASTOR-RC, se reingreso la solicitud de ampliación de plazo, debidamente sustentada, precisando la causal y cuantificando los días a solicitar. Sin embargo, la **DEMANDADA** mediante Resolución de Gerencia General N° 020-2022-SEDA AYACUCHO/GG, declara improcedente nuestra solicitud, argumentando "… *no procede una segunda solicitud por las mismas causales y medios probatorios ya evaluados y que ya fue objeto de pronunciamiento expreso, y que en caso*

de existir controversia relacionada con la ampliación del plazo puede ser sometida a conciliación y/o arbitraje…".

6.11 Al respecto, debe precisarse que en el primer acto administrativo que deniega nuestra solicitud de ampliación de plazo, en ningún extremo realiza un análisis de la causal señalada en nuestro pedido y de los medios probatorios adjunto a ella (Carta N° 001-2022/FUMOSAC), siendo que el argumento para que la solicitud fuera desestimada, obedece a aspectos formales señalados en la Ley de Contrataciones del Estado y no a la evaluación de fondo del petitorio. Considerando ello, lo referido en la Resolución de Gerencia General N° 020-2022-SEDA AYACUCHO/GG, carece de veracidad.

6.12 En la solicitud de ampliación de plazo, se señaló el "hecho generador", el cual fue la falta de producción de los bienes por parte de la empresa Fundición Moreno S.A.C., ello debido a las restricciones dadas por el Gobierno Central debido a la tercera ola y aumento de casos positivos de COVID-19 en sus trabajadores, lo que imposibilitaba que la empresa pueda cumplir con lo requerido por nuestra parte dentro de los plazos pactados. Dicha situación fue ajena a la voluntad del **CONSORCIO**, correspondiendo ampliarse el plazo.

6.13 De acuerdo con el artículo 34.2 del T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el contrato puede ser modificado en el supuesto que se autorice la ampliación del plazo contractual. Por su parte, el artículo 158.1 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, manifiesta que procede la ampliación de plazo en el caso de atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista.

6.14 Estando al derecho positivo ut supra descrito, debemos indicar que, en la ejecución del Contrato N° 033-2021-SEDA AYACUCHO/G.G., se ha producido una paralización no imputable al **CONSORCIO** en su calidad de contratista que ha ocasionado que los bienes descritos en su artículo tercero, no sean entregados -dentro de los 25 días calendarios.

6.15 Ahora, la **ENTIDAD** ha venido manifestando que *"la declaratoria de emergencia por la propagación del COVID 19, fue con anterioridad y como tal ya no constituyen un hecho extraordinario e imprevisible",* al respecto, es pertinente manifestar la tercera ola del COVID 19, es un hecho nuevo, posterior a la suscripción del contrato. Asimismo, corresponde desarrollar si la Emergencia Sanitaria es un escenario de caso fortuito y fuerza mayor. Para tal fin, es pertinente señalar lo referido en el Comunicado N° 05-2020 del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE):

> *"(…) en el marco de las normas que establecen medidas excepcionales para contener la propagación del Coronavirus (COVID-19), hace de conocimiento lo siguiente en relación con la ejecución de contratos:*

1. La declaratoria de estado de emergencia nacional dispuesta mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, precisado con Decreto Supremo N° 046-2020PCM, ***constituye una situación de fuerza mayor*** *que puede afectar los vínculos contractuales celebrados al amparo de la normativa de contrataciones del Estado, tanto del lado del contratista como del lado de la Entidad contratante." (Énfasis agregado)*

6.16 A ello, debemos señalar que la declaratoria de la Tercera Ola, ello ante el incremento del COVID 19 en enero de 2022 y las restricciones dispuestas por el Gobierno Central, constituye un evento ajeno tanto para el **CONTRATISTA** como para la **ENTIDAD**, lo cual califica como un evento de fuerza mayor que le impidió al **CONSORCIO** cumplir con sus obligaciones en el plazo, puesto que es:

a. **Extraordinario**: No resulta común que el Gobierno Peruano declare Estado de Emergencia a toda la Nación y ésta sea ampliada continuamente (para enero de 2022, a través del Decreto Supremo N° 002-2022-PCM).
b. **Imprevisible**: Una vez conocido el COVID-19 surgido en China; no era previsible que ésta se convirtiera en la mayor pandemia viral en la historia de la humanidad contemporánea y que ésta mute constantemente siendo cada vez más contagiosa.
Al respecto, se debe considerar que, si bien podía especularse de la tercera ola, sin embargo, no se tenía fecha exacta o certeza de cuando ocurriría tal evento, hasta que el Ministerio de Salud lo oficializó el 04 de enero de 2022.
c. **Irresistible**: Ninguna de las partes puede resistir u oponerse a una disposición emitida por el Gobierno Peruano. Por un lado, las empresas privadas (incluida Fundición Moreno S.A.C.), estaban obligados a reducir el número de trabajadores en planta, asimismo, tuvo que cumplir con aislar a los trabajadores contagiados con COVID, lo que generó una disminución en su producción.
Por otro lado, ante el incremento de los contagios del COVID 19, la **ENTIDAD**, se vio obligada a suspender la atención presencial, tal como se puede apreciar en su comunicado N° 002-2022, difundido a través de las redes sociales:

SEDA AYACUCHO
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A.
Llevamos vida a tu hogar

Nro.02 -2022

COMUNICADO

SEDA Ayacucho se dirige a sus usuarios de Huamanga para dar a conocer lo siguiente:

1. Que, ante el incremento de contagios del COVID - 19 en nuestra ciudad y en cumplimiento del Decreto Supremo N°002-2022-PCM **a partir del 21 al 31 de enero del año en curso, se suspenderá las atenciones presenciales en nuestras ventanillas de cobranza, atención de reclamos comerciales y ventas de conexiones nuevas.**

6.17 Ahora bien, habiéndose demostrado que los eventos ocurridos en enero de 2022 que incluso, obligaron a la misma **ENTIDAD** a suspender la atención presencia, no es coherente su decisión de declarar la improcedencia de nuestra solicitud de ampliación de plazo y más aún su consideramos que en su respuesta no se cumple con evaluar de manera adecuada, los medios probatorios adjuntos.

6.18 Mediante escrito del 27 de julio de 2022, el **CONSORCIO** precisa que en su primera pretensión se cuestiona la improcedencia a la solicitud de ampliación de plazo presentado mediante Carta N° 002-2022/CONSORCIO ASTOR-RC, escrito en donde se cumplió con sustentar la causal y se cuantificó los días solicitados. Agrega que dicha solicitud fue atendida por la **ENTIDAD** mediante Resolución de Gerencia General N° 020-2022-SEDA AYACUCHO/GG en la que señala: *"no procede una segunda solicitud por las mismas causales y medios probatorios ya evaluados y que ya fue objeto de pronunciamiento expreso, y que en caso de existir controversia relacionada con la ampliación de plazo puede ser sometida a conciliación y/o arbitraje"*.

El **CONSORCIO** señala que, en la referida resolución, la **ENTIDAD** no se pronuncia sobre los medios probatorios ofrecidos por el **DEMANDANTE**, así como por la causal invocada.

6.19 Con fecha 08 de setiembre de 2022, el **CONSORCIO** precisa que en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, no se señala como requisito que la ampliación de plazo deba presentarse dentro del plazo de ejecución contractual, ya que solamente se indica que ésta deberá presentarse dentro de los siete días hábiles siguientes de finalizado el hecho generador, por lo que se entiende que estas solicitudes pueden ser presentadas fuera del plazo de ejecución contractual.

6.20 Mediante escrito del 17 de octubre de 2022, el **DEMANDANTE** presentó las Guías de Remisión N° 007441, 007442, 007443, 007444, 007446, 007447, 007450, 007452, 007453, 007454, 007455, 007456, 007458, 007459, 007460, 007461, 007464, 007465, 007466, 007467 y 007468. Al respecto, el

CONSORCIO indica que la última entrega se realizó el 07 de febrero de 2022, tal como se aprecia en la Guía de Remisión N° 007468.

Posición de la ENTIDAD:

6.21 **SEDA AYACUCHO** en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento procedió a resolver la solicitud de ampliación de plazo presentado por el **DEMANDANTE**, declarándola improcedente, por cuanto el **CONSORCIO** en su solicitud no cuantificó la ampliación de plazo, es decir, la cantidad de días que requería para cumplir con sus obligaciones contractuales. Sobre ello, el artículo 198 numeral 198.1 del Reglamento establece:

> *"198.1 Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen la ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada,* ***el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo*** *ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente".*

Agrega la **ENTIDAD** que, como se observa del citado dispositivo, corresponde al **CONTRATISTA** sustentar y cuantificar la solicitud de ampliación de plazo, tomando en cuenta las circunstancias que, a su criterio, determinen la ampliación del plazo de ejecución contractual en la obra, bien o servicio a su cargo.

6.22 En consecuencia, la **ENTIDAD** declaró improcedente la solicitud de ampliación de plazo, por cuanto el **CONSORCIO** no señaló la cantidad de días que requería para cumplir con sus obligaciones contractuales, conforme se aprecia de los fundamentos expuestos en la Resolución N° 012-2022-SEA AYACUCHO/GG.

6.23 Con fecha 18 de agosto de 2022, **SEDA AYACUCHO** señaló que respecto a la segunda solicitud de ampliación de plazo efectuado por el **CONSORCIO** mediante Carta N° 002-2022/CONSORCIO ASTOR-RC, el mismo que fue atendido mediante Resolución de Gerencia General N° 020-2022-SEDA AYACUCHO/GG, declarando improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo del Contrato N° 033-2021-SEDA AYACUCHO/GG, debido a que no procede una segunda solicitud por las mismas causales y medios probatorios ya evaluados y que ya fue objeto de pronunciamiento expreso

en un acto administrativo precedente. Agrega la **ENTIDAD** que, el segundo pedido de ampliación de plazo solicitado por el **CONSORCIO** fue realizado fuera del plazo de ejecución contractual, es decir, el plazo contractual establecido en la Cláusula Quinta del Contrato N° 033-2021-SEDA AYACUCHO/GG estableció un plazo de 25 días calendarios, el mismo que se computaba desde el día siguiente de la suscripción del contrato, el cual fue suscrito el 23 de diciembre de 2021, por lo que el plazo de ejecución contractual fue del 24 de diciembre de 2021 al 17 de enero de 2022; sin embargo, la Carta N° 002-2022/CONSORCIO ASTOR-RC fue presentada el 28 de enero de 2022, es decir, fuera del plazo de ejecución contractual, por lo que deviene en improcedente.

Posición del ÁRBITRO ÚNICO:

6.24 Mediante Carta N° 001-2022/CONSORCIOASTOR-RC de fecha 13 de enero de 2022, el **CONSORCIO** solicitó a la **ENTIDAD** la ampliación de plazo para la entrega de los bienes materia del Contrato. En razón de ello, la **DEMANDADA**, mediante Carta N° 004-2022-SEDA AYACUCHO- GAF-DLSG/ESPEJEC, notificó al **DEMANDANTE** la Resolución Gerencial General N° 012-2022-SEDA AYACUCHO/GG, en la cual declaró improcedente la solicitud de ampliación de plazo, debido a que el **CONTRATISTA** no cumplió con cuantificar los días de la ampliación de plazo a solicitar.

6.25 En tal sentido, con fecha 28 de enero de 2022, el **CONSORCIO** presentó a la **ENTIDAD** la Carta N° 002-2022/CONSORCIOASTOR-RC, en la cual solicitaba la ampliación de plazo del Contrato por cuarentaicinco (45) días adicionales. Como respuesta de ello, la **ENTIDAD** expidió la Resolución de Gerencia General N° 020-2022-SEDA AYACUCHO/GG del 10 de febrero de 2022, en la cual se declaró improcedente la solicitud de ampliación de plazo, bajo el siguiente argumento:

> *"Por todo lo mencionado y estando a los antecedentes, la señora Frida Asto Reza, representante legal del CONSORCIO ASTOR, con Carta N° 001-2022/CONSORCIOASTOR-RC, de fecha 13 de enero de 2022, solicitó ampliación de plazo, la misma que con Resolución de Gerencia General N° 012-2021-SEDA AYACUCHO/GG, de fecha 26 de enero de 2022, se declaró IMPROCEDENTE; y con fecha 28 de enero de 2022 vuelve a presentar una segunda solicitud de ampliación de plazo,* ***por las mismas causales y medios probatorios ya evaluados y que fue objeto de pronunciamiento****. Por lo que debe declararse improcedente la nueva solicitud de ampliación de plazo por 45 días calendario, y de considerarlo, el contratista tiene expedito su derecho de acudir a la conciliación y/o arbitraje"*

6.26 Sobre el particular, debemos señalar que al momento de resolver el pedido de ampliación de plazo presentado con fecha 13 de enero de 2022, la **ENTIDAD** manifestó en la Resolución Gerencial General N° 012-2022-SEDA AYACUCHO/GG, lo siguiente:

> *"Del análisis, de la Carta N° 001-2022/CONSORCIOASTOR-RC, de fecha 13 de enero de 2022, mediante el cual la señora Frida Asto Reza, representante legal del CONSORCIO ASTOR, solicita la ampliación de plazo, para dar cumplimiento al contrato N° 033-2021-SEDA AYACUCHO/GG, si bien se observa las circunstancias invocadas como causal de ampliación de plazo, sin embargo en la solicitud* ***no ha cuantificado el plazo adicional que resulte necesario para culminar su prestación****; por lo que la Entidad no puede evaluar la pertinencia de otorgar una ampliación de plazo, ya que la evaluación se realiza en función a la cuantificación del plazo por parte del contratista, por lo que no se estaría cumpliendo con los requisitos de procedencia de una ampliación de plazo".*

En ese sentido, se puede apreciar de la lectura de la citada resolución que, la **ENTIDAD** no ingreso a analizar los argumentos de fondo de la solicitud de ampliación de plazo, sino que se basó en la omisión por parte del **CONTRATISTA** de cuantificar los días de la ampliación de plazo, para declarar la improcedencia de la solicitud formulada.

Es decir, el pronunciamiento de **SEDA-AYACUCHO** se ha limitado a analizar si el **CONSORCIO** cumplió o no con cuantificar el plazo; sin analizar los demás argumentos expuestos en la referida solicitud, lo cual se encuentra acreditado al tenor de lo indicado en dicha resolución: "*…la Entidad no puede evaluar la pertinencia de otorgar una ampliación de plazo, ya que la evaluación se realizar en función a la cuantificación del plazo por parte del contratista*".

6.27 Por otro lado, el **CONSORCIO** presentó con fecha 28 de enero de 2022 una solicitud de ampliación de plazo mediante la Carta N° 002-2022/CONSORCIOASTOR-RC, en la cual solicitaba la ampliación de plazo del Contrato por cuarentaicinco (45) días adicionales. Ante tal pedido, la **ENTIDAD** expidió la Resolución de Gerencia General N° 020-2022-SEDA AYACUCHO/GG del 10 de febrero de 2022, en la cual se declaró improcedente la solicitud de ampliación de plazo, bajo el argumento de que las causales y medios probatorios presentados con fecha 28 de enero de 2022, fueron los mismos que el **CONTRATISTA** había presentado el 13 de enero de 2022; y que tales causales y medios probatorios ya habían sido objeto de pronunciamiento expreso.

6.28 No obstante lo indicado por la **ENTIDAD**, de la revisión y análisis de los medios probatorios presentados por las partes, se puede apreciar que en la Resolución Gerencial General N° 012-2022-SEDA AYACUCHO/GG no obra un pronunciamiento expreso respecto de todos los argumentos y medios probatorios presentados por el **CONSORCIO** en su solicitud de ampliación de plazo presentado el 13 de enero de 2022, por lo cual no se puede concluir que en la citada resolución, la **ENTIDAD** se pronunció sobre los aspectos del fondo del pedido formulado.

6.29 Al respecto, se debe tener presente, que el **CONSORCIO** en su solicitud de ampliación de plazo presentado el 13 de enero de 2022 mediante la Carta N° 001-2022/CONSORCIOASTOR-RC manifestó expresamente:

> *"Que con fecha 23 de Diciembre de 2021, la entidad y mi representada suscribimos el contrato N°033-2021-SEDA-AYACUCHO/G.G. Del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 010-2021-SEDA AYACUCHO/CS SEGUNDA CONVOCATORIA, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS EN H°D°, F°F° Y OTROS PARA SEDA AYACUCHO.*
>
> *A la fecha se viene produciendo las válvulas y accesorios de H°D°, F°,F° Y OTROS de distintos modelos y medidas conforme se ha detallado en el contrato; sin embargo, se han presentado dificultades en la producción en algunos productos en especial en la marca FUMOSAC.*
>
> *La misma que a través de la CARTA N° 001-2022/FUMOSAC, de fecha 11 de Enero de 2021 nos manifiesta que por motivos de inventario de fin de año en la última semana del mes de diciembre de 2021 ni tuvieron producción de las válvulas y accesorios de H°D°, F°F° Y OTROS y además vienen laborando con un 50% de personal por la pandemia del COVID-19.*
>
> *También señala que nos estará entregando las Válvulas y accesorios de H°D°, F°F° Y OTROS el día 28 de febrero del presente año.*
>
> *En atención a ello se adjunta la carta de la empresa FUNCIONES MORENO SAC, CARTA N° 001-2022/FUMOSAC, como sustento por haberse suscitado un caso fortuito.*
>
> *En consecuencia estando dentro del plazo vigente solicito a que me amplié el plazo de entrega. Todo esto en virtud al Art. 175, numeral 4, del Reglamento de Contrataciones del Estado."*

Ahora bien, en la Resolución de Gerencia General N° 012-2022-SEDA AYACUCHO del 26 de enero de 2022, con la cual se da respuesta a la solicitud de ampliación de plazo presentada el 13 de enero de 2022, la **ENTIDAD** manifiesta lo siguiente en el tercer y cuarto considerando:

> *"Que, con Carta N° 001-2022/CONSORCIOASTOR-RC, de fecha 13 de enero del 2022, la señora Frida Asto Reza, representante legal del CONSORCIO ASTOR, solicita la ampliación de plazo, para dar cumplimiento al contrato N° 033-2021-SEDA AYACUCHO/GG, argumentando que ala fecha se viene produciendo las válvulas y accesorios en H°D°, F°F° y otros de distintos modelos y medidas conforme se ha detallado en el contrato, sin embargo se han presentado dificultades en la producción en algunos productos en especial de la marca FUMOSAC conforme sustenta con la Carta*

N° 001-2022/FUMOSAC, de fecha 11 de enero de 2021, mediante el cual el Gerente de la empresa Fundición Moreno SAC – FUMOSAC, pone en conocimiento que por motivos de inventario no tuvieron la última producción de diciembre y que vienen laborando con el 50% de personal por la pandemia del COVID-19, con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19, en merito a la R.M. N° 1275-2020-MINSA y la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Art. 60), y que se presentaron varios casos positivos a COVID 19, afectando el avance de la producción y que estarán entregando la válvulas y accesorios H°D°, F°F° y otros el día 28 de febrero del presente año; por lo que estando dentro del plazo vigente solicita ampliación de plazo de entrega, en virtud al artículo 175 numeral 4 del Reglamento de Contrataciones del Estado (Sic);

Que, con Informe N° 010-2022-SEDA AYACUCHO-GGOOADL, la Jefa de la Oficina de Asesoría y Defensa Legal, ***previa análisis y evaluación de las causales invocadas por el contratista, recomienda declarar improcedente la ampliación de plazo del contrato N° 033-2021-SEDA AYACUCHO/GG, ya que el contratista no ha cuantificado el plazo adicional que resulte necesario para culminar su prestación; por lo que la Entidad no puede evaluar la pertinencia de otorgar una ampliación de plazo****, ya que la evaluación se realiza en función a la cuantificación del plazo por parte del contratista".* (el sombreado es nuestro)

De la lectura de la mencionada resolución se puede advertir tal como se ha manifestado en los párrafos precedentes, que la propia **ENTIDAD** ha señalado expresamente que no pudo ingresar a analizar las causales invocadas en la solicitud formulada por el **CONSORCIO** debido a que no cuantificó el plazo adicional requerido. En atención a ello, se reitera que la **ENTIDAD** en ningún momento analizó los argumentos expuestos por el **DEMANDANTE**, limitándose a indicar que no cumplió con la cuantificación requerida para realizar la evaluación respectiva.

6.30 Por otro lado, la **ENTIDAD** ha manifestado que declaró improcedente la solicitud de ampliación de plazo presentada el 28 de enero de 2022 mediante la Carta N° 001-2022/CONSORCIOASTOR-RC, debido a que no procede una segunda solicitud por las mismas causales y medios probatorios ya evaluados y que ya fue objeto de pronunciamiento expreso en un acto administrativo precedente.

Con relación a este argumento, se debe manifestar que el pedido formulado con fecha 28 de enero de 2022 no constituye un nuevo pedido de ampliación de plazo por las mismas causales del presentado con fecha 13 de enero de 2022, toda vez que al resolver la solicitud presentada el 13 de enero de 2022, no se analizaron los argumentos de fondo que se manifestaron en dicha solicitud. Es decir, el pedido presentado el 13 de enero de 2022 fue declarado improcedente sin analizar las causales

argumentadas por el **CONSORCIO**, amparándose únicamente en la no cuantificación del plazo requerido.

En ese mismo sentido, se debe tener presente que mediante la Resolución de Gerencia General N° 020-2022-SEDA AYACUCHO del 10 de febrero de 2022, con la cual se da respuesta a la solicitud de ampliación de plazo presentada con fecha 28 de enero de 2022, tampoco se analizaron los argumentos de fondo expuestos por el **DEMANDANTE**, sosteniendo que no se puede presentar una segunda solicitud de ampliación de plazo por las mismas causales:

> *"Que, con Informe N° 020-2022-SEDA AYACUCHO-GGOOADL, la Jefa de la Oficina de Asesoría y Defensa Legal, previo análisis y evaluación de la solicitud de ampliación del plazo pone en conocimiento que, la señora Frida Asto Reza, representante legal del CONSORCIO ASTOR, mediante Carta N° 001-2022/CONSORCIO ASTOR-RC, de fecha 13 de enero del 2022, solicitó ampliación de plazo, la misma que con Resolución de Gerencia General N° 012-2021-SEDA AYACUCHO/GG, de fecha 26 de enero del 2022, se declaró IMPROCEDENTE; por lo que* ***no procede una segunda solicitud por las mismas causales y medios probatorios ya evaluados y que ya fue objeto de pronunciamiento expreso****, y que en caso de existir controversia relacionada con la ampliación de plazo puede ser sometida a conciliación y/o arbitraje. Por lo que recomienda declarar improcedente la nueva solicitud de ampliación de plazo".* (lo sombreado es nuestro)

Lo afirmado en la mencionada resolución no se ajusta a la realidad de los hechos, toda vez que la **ENTIDAD** no ingreso a analizar las causales invocadas por el **CONSORCIO** y tampoco realizó un análisis sobre los medios probatorios presentados en dicha solicitud. En atención a ello, no es amparable el argumento expuesto por la **ENTIDAD**, debido a que las causales y medios probatorios expuestos por el **CONSORCIO** nunca fueron materia de pronunciamiento expreso por parte de la **DEMANDADA** al momento de resolver las solicitudes presentadas el 13 de enero de 2022 y del 28 de enero de 2022.

6.31 Ahora bien, la **ENTIDAD** también ha sostenido que, el segundo pedido de ampliación de plazo solicitado por el **CONSORCIO** fue realizado fuera del plazo de ejecución contractual, es decir, el plazo contractual establecido en la Cláusula Quinta del Contrato N° 033-2021-SEDA AYACUCHO/GG estableció un plazo de 25 días calendarios, el mismo que se computaba desde el día siguiente de la suscripción del contrato, el cual fue suscrito el 23 de diciembre de 2021, por lo que el plazo de ejecución contractual fue del 24 de diciembre de 2021 al 17 de enero de 2022; sin embargo, la Carta N° 002-2022/CONSORCIO ASTOR-RC fue presentada el 28 de enero de 2022, es decir, fuera del plazo de ejecución contractual, por lo que deviene en improcedente.

6.32 Al respecto, debemos indicar que el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece lo siguiente:

> *"Artículo 158. Ampliación del plazo contractual*
> *158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos:*
> *a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.*
> *b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista.*
> *158.2. El contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. 158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.*
> *158.4. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal.*
> *158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios en general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En el caso de la consultoría de obras, se paga al contratista el gasto general y el costo directo, este último debidamente acreditado, además de la utilidad.*
> *158.6. Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo puede ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la notificación de esta decisión."*

De la lectura del citado dispositivo, se puede apreciar que la norma no establece como requisito para la presentación de la solicitud de ampliación de plazo, que la misma se presente dentro del plazo de ejecución contractual. Asimismo, se debe tener presente que la **ENTIDAD** no ha señalado en que artículo se encuentra recogido el argumento que busca se ampare, por lo cual debe ser desestimado.

En ese mismo sentido, la Dirección Técnica Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, en la Opinión N° 042-2016/DTN del 10 de marzo de 2016, estableció lo siguiente:

> *"En esa medida, la solicitud de ampliación de plazo, en el caso de bienes y servicios, puede presentarse con anterioridad o posterioridad al término del plazo de ejecución contractual, <u>pero siempre dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o la finalización del hecho generador del atraso o paralización</u>."*

En la referida Opinión también se menciona lo siguiente a tener presente:

"De conformidad con lo señalado en el numeral 2.1.1 de la Opinión N° 045-2014/DTN, se entiende por plazo de ejecución contractual al periodo en que el contratista se ha obligado a ejecutar las prestaciones a su cargo; a diferencia del plazo de vigencia del contrato, el cual inicia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene o, en su caso, desde la recepción de la orden de compra o de servicio hasta el otorgamiento de la conformidad de las prestaciones a cargo del contratista y el pago correspondiente."

6.33 Habiendo desestimado los argumentos expuestos por la **ENTIDAD** para desestimar el pedido de ampliación de plazo formulado por el **CONSORCIO**, en atención a lo establecido en el primer punto controvertido, corresponde al Árbitro Único analizar si corresponde o no amparar la solicitud formulada mediante Carta N° 002-2022/CONSORCIOASTOR/RC.

En tal sentido, mediante la referida carta, el **DEMANDANTE** señaló lo siguiente:

"De acuerdo a las bases integradas del procedimiento de selección, no se requirió que los postores cuenten con el stock de los materiales requerido por la Entidad, toda vez que éstos no son comerciales, razón por la que fijo como plazo de prestación de servicio 25 días calendarios, tiempo en el que el contratista cuenta para la adquisición de éstos.

Durante el procedimiento de selección, el consorcio realizó las cotizaciones de los bienes (en noviembre de 2021), donde nos garantizaron la entrega de los bienes dentro del plazo establecido (25 días calendarios). Y, conforme puede advertirse el contrato fue suscrito el 23 de diciembre de 2021, habiendo transcurrido casi un mes desde la realización de la cotización de los bienes. Ahora, posterior a la suscripción del contrato, nuestra parte se comunicó con nuestros proveedores a fin de que se fabriquen los materiales requeridos; sin embargo, grande fue nuestra sorpresa al recibir su respuesta, quienes manifestaron no contar con el stock suficiente de los materiales, por lo que no era posible atender nuestro pedido.

Mediante Carta N° 001-2022/FUMOSAC, el Gerente General de la empresa Fundición Moreno S.A.C, nos comunica:

(…) comunicamos a su representada que por motivos de inventario no tuvimos producción la última semana de diciembre, además le informamos que venimos laborando en la actualidad con un 50% de personal por la pandemia del COVID-19, todo esto con la finalidad de evitar la propagación de COVID-19, en merito a R.M. 1275-2020-

MINSA y Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Art. 60), asimismo en nuestra empresa Fundición Moreno SAC también se presentaron más casos positivos de COVID 19, afectando el avance de la producción.
Por lo expuesto y a fines de poder cumplir con el requerimiento de nuestro cliente, solicitamos a su representada ampliación de plazo para la entrega de accesorios en H°D° Y OTROS por lo que estaremos enviando el pedido el 28 de febrero del presente.

Como es de advertirse, la empresa encargada de la producción de los bienes requeridos por la ENTIDAD, no podrá atender nuestro requerimiento, ello debido al incremento de los casos positivos de COVID 19 en sus trabajadores, por lo que estiman que, para el 28 de febrero de 2022 se estará cumpliendo con enviar los bienes. Asimismo, a ello se debe agregar que a raíz de la comunicación del comienzo de la tercera ola de COVID 19 en el Perú (04 de enero de 2022), el Gobierno Central ha implementado nuevas restricciones, limitando la capacidad de producción de la empresa.

Este hecho extraordinario e imprevisible (infección de COVID 19 de los trabajadores de la empresa encargada de fabricar los bienes y nuevas medidas restrictivas a causa de la tercera ola de COVID 19), viene limitando las labores de producción de la empresa, toda vez que no cuenta con el total de su personal laborando. Lo referido anteriormente, es demostrado a través de la Carta remitida por el proveedor, así como las noticias referentes a las restricciones ordenadas por el Gobierno Central para hacer frente a la tercera ola.

Como se puede apreciar ante los hechos expuestos anteriormente, la demora acontecida no es atribuible a mi representada en ningún extremo, y por tanto, se solicita la ampliación de plazo contractual, debidamente comprobada la misma que desprende un hecho ajeno, el cual se encuentra regulado en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento".

6.34 Ahora bien, la **ENTIDAD** en su escrito de contestación de la demanda ha manifestado que se amparó en el artículo 198 numeral 198.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para declarar improcedente la solicitud de ampliación de plazo. Sin embargo, dicho artículo se encuentra dentro del Capítulo VI del citado Reglamento, el cual establece las disposiciones para "Obras"; y en el caso materia de litis nos encontramos ante un contrato de adquisición de bienes, tal como figura en la Cláusula Segunda del Contrato N° 033-2021-SEDA-AYACUCHO/G.G. "Adquisición de Accesorios en H°D°, F°F° y otros para Seda Ayacucho".

Es por ello que, la disposición aplicable para analizar la solicitud de ampliación de plazo formulado por el **CONSORCIO** es el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

6.35 Por su parte, en la Carta N° 002-2022/CONSORCIOASTOR/RC, el **CONSORCIO** ha señalado que lo acontecido configura un hecho imprevisible y por ende, corresponde que se apruebe la solicitud de ampliación de plazo. Y fundamenta su pedido en lo establecido en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en donde se estipula que procede la ampliación de plazo por atrasos y/o paralizaciones no imputables al **CONTRATISTA**.

6.36 Al respecto, la Dirección Técnica Normativa del OSCE en la Opinión N° 024-2022/DTN del 05 de abril de 2022, estableció lo siguiente en el numeral 2.1.1:

> *"En principio, debe indicarse que durante la ejecución de los contratos celebrados al amparo de la normativa de Contrataciones del Estado1 pueden surgir eventos que ocasionan atrasos y paralizaciones, ajenos a la voluntad de las partes y debidamente comprobados, que modifican el plazo contractual. En ese contexto, el numeral 34.9 del artículo 342 de la Ley establece que el contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado según lo dispuesto en el Reglamento.*
> ***Al respecto, tratándose de las contrataciones de bienes y servicios, el artículo 158 del Reglamento establece que la ampliación de plazo contractual procede cuando**: (i) se aprueba la ejecución de una prestación adicional, siempre y cuando ésta afecte el plazo; y, **(ii) por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista.***
> *En ese sentido, la ampliación del plazo de ejecución contractual es un supuesto de modificación contractual que implica la variación del plazo de ejecución contractual, es decir, la Entidad le otorga al contratista un mayor plazo —al originalmente pactado en el contrato— para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, por causas no imputables a éste (relacionadas con los supuestos mencionados en el párrafo anterior)."* (el sombreado es nuestro)

Por su parte, en la Opinión N° 019-2017/DTN del 06 de setiembre de 2017, la Dirección Técnica Normativa del OSCE sostuvo:

> *"De las disposiciones citadas, se aprecia que la normativa de contrataciones del Estado prevé la posibilidad de que el contratista pueda solicitar la ampliación del plazo pactado, por atrasos y/o paralizaciones no imputables a este; debiendo precisarse que, en dicho contexto, corresponde a la Entidad -antes de aplicar la "penalidad por mora en la prestación"- **determinar si se configura dicha causal**, a efectos de resolver la solicitud de ampliación de plazo y notificar su decisión al contratista, conforme a lo establecido en el Reglamento.*
> *(…)*

2.4 Ahora bien, en atención al tenor de la consulta planteada, resulta propicio tomar en consideración los conceptos de "caso fortuito o fuerza mayor" que contempla el artículo 1315 del Código Civil (de aplicación supletoria a los contratos que se ejecutan bajo el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado, conforme a lo establecido en la Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento), el cual establece que "Caso fortuito o fuerza mayor ***es la causa no imputable****, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso." (El subrayado es agregado).*

Al respecto, es necesario precisar que un hecho o evento extraordinario se configura cuando, tal como lo indica la misma palabra, sucede algo fuera de lo ordinario, es decir, fuera del orden natural o común de las cosas.

Asimismo, un hecho o evento es imprevisible cuando supera o excede la aptitud razonable de previsión del deudor en la relación obligatoria, puesto que el deudor tiene el deber de prever lo normalmente previsible, no así lo imprevisible.

Por su parte, el que un hecho o evento sea irresistible significa que el deudor no tiene posibilidad de evitarlo, es decir, no puede impedir, por más que lo desee o intente, su acaecimiento.

De esta manera, se advierte que la configuración de un "caso fortuito o fuerza mayor" exime de responsabilidad a las partes, específicamente, a la parte que se ve imposibilitada de ejecutar las prestaciones a su cargo."

6.37 Al respecto, debemos señalar que con fecha 04 de enero de 2022, el Ministro de Salud, Hernando Cevallos Flores confirmó que el Perú ya atravesaba la tercera ola ante el incremento de casos de contagio por la COVID-19. Indicó que la variante ómicron se encuentra en Lima, Callao y en distintas regiones del país.[1]

En conferencia de prensa, Cevallos Flores indicó que, durante el mes de diciembre, comparando las semanas epidemiológicas 49 y 52, los casos de COVID-19 se duplicaron en Lima Metropolitana y se incrementaron en más del 50 % a nivel nacional, con lo que se confirma el inicio de la tercera ola.

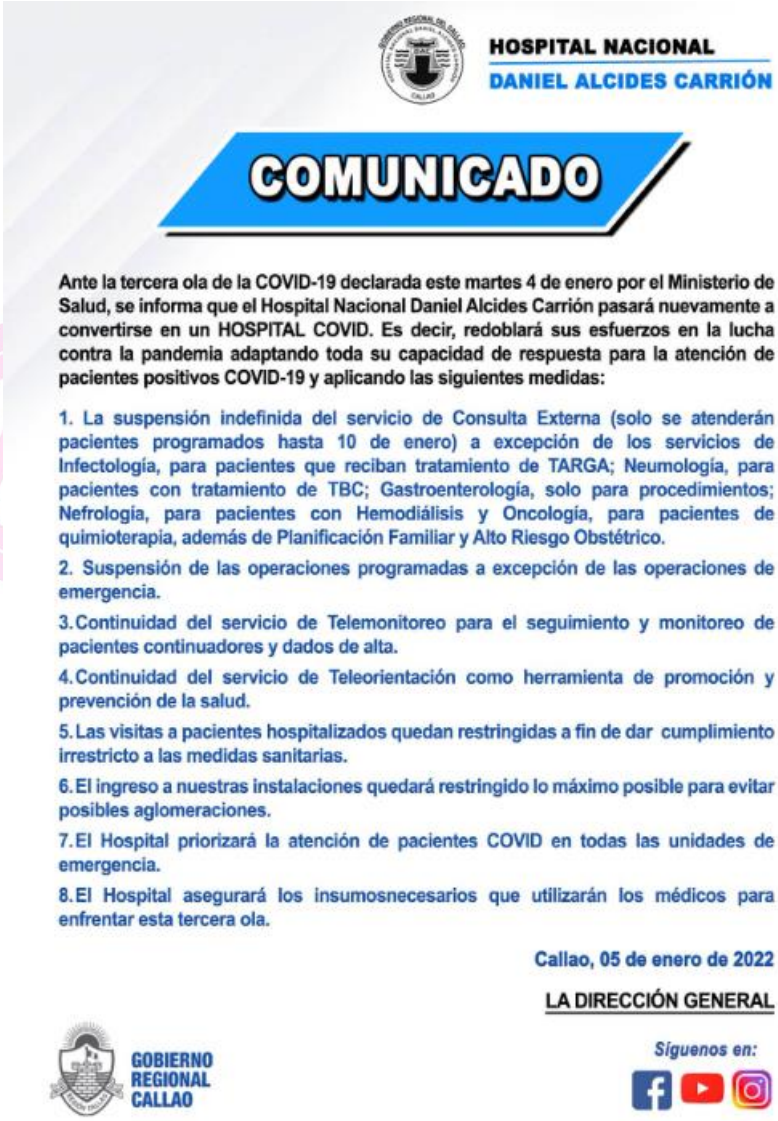
En ese sentido, afirmó que "De hecho en la última semana epidemiológica del año 2021, los casos de COVID-19 se incrementaron en un 25 %, específicamente pasaron de 11 766 a 14 688 casos", informó.

El titular de Salud sostuvo que, según el último reporte de vigilancia genómica la variante Ómicron ya se ha convertido en la variante predominante en Lima Metropolitana, mayor al 53 %, habiéndose reportado ya en 10 regiones: Lima Provincias, Callao, Piura, Loreto, La Libertad, Huánuco, Áncash, Ica, Arequipa y Apurímac.

[1] Fuente: Nota de Prensa del Ministerio de Salud del 04 de enero de 2022.

6.38 De igual forma, el domingo 06 de enero de 2022, el Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Augusto Tarazona manifestó que: *"De continuar esta tendencia, la próxima semana puede llegar a los 100.000 casos, quien anticipó que las autoridades peruanas proyectan que el pico de esta tercera ola se dé a finales de enero, cuando podrían alcanzarse los 150.000 nuevos contagios a la semana, lo que sería una situación bastante difícil"*[2].

6.39 Asimismo, se debe tener presente los comunicados emitidos por las distintas dependencias del país, como es el caso del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, quien con fecha 05 de enero de 2022 señaló lo siguiente:



HOSPITAL NACIONAL
DANIEL ALCIDES CARRIÓN

COMUNICADO

Ante la tercera ola de la COVID-19 declarada este martes 4 de enero por el Ministerio de Salud, se informa que el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión pasará nuevamente a convertirse en un HOSPITAL COVID. Es decir, redoblará sus esfuerzos en la lucha contra la pandemia adaptando toda su capacidad de respuesta para la atención de pacientes positivos COVID-19 y aplicando las siguientes medidas:

1. La suspensión indefinida del servicio de Consulta Externa (solo se atenderán pacientes programados hasta 10 de enero) a excepción de los servicios de Infectología, para pacientes que reciban tratamiento de TARGA; Neumología, para pacientes con tratamiento de TBC; Gastroenterología, solo para procedimientos; Nefrología, para pacientes con Hemodiálisis y Oncología, para pacientes de quimioterapia, además de Planificación Familiar y Alto Riesgo Obstétrico.
2. Suspensión de las operaciones programadas a excepción de las operaciones de emergencia.
3. Continuidad del servicio de Telemonitoreo para el seguimiento y monitoreo de pacientes continuadores y dados de alta.
4. Continuidad del servicio de Teleorientación como herramienta de promoción y prevención de la salud.
5. Las visitas a pacientes hospitalizados quedan restringidas a fin de dar cumplimiento irrestricto a las medidas sanitarias.
6. El ingreso a nuestras instalaciones quedará restringido lo máximo posible para evitar posibles aglomeraciones.
7. El Hospital priorizará la atención de pacientes COVID en todas las unidades de emergencia.
8. El Hospital asegurará los insumosnecesarios que utilizarán los médicos para enfrentar esta tercera ola.

Callao, 05 de enero de 2022

LA DIRECCIÓN GENERAL

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

Síguenos en:

6.40 En atención a lo antes expuesto, se puede apreciar que el Poder Ejecutivo declaro el inició de la tercera ola del Covid-19 el 04 de enero de 2022, debido al incremento de casos positivos detectados desde la última semana de diciembre de 2021. En ese sentido, resultado evidente y notorio

[2] Fuente: Diario El Comercio del día 11 de enero de 2022.

que desde finales del 2021 el Perú atravesaba un incremento de contagios con el Covid-19, lo cual a su vez generó una disminución de la fuerza laboral tanto en las distintas empresas de nuestro país, como en las dependencias públicas.

6.41 Si bien, es cierto que en el Perú se declaró la pandemia del Covid-19 desde el mes de marzo de 2020, también es cierto que en determinados periodos de tiempo se incrementaron los números de contagios, los cuales fueron denominados como la "primera ola", "segunda ola", "tercera ola" y "cuarta ola". De igual forma, no era previsible el poder determinar en qué momento exactamente iba a ver un incremento de los contagios con la referida enfermedad, ya que los mismos se producían en la medida que una nueva variante del Covid 19 llegaba a nuestro país. Es por ello que, cada incremento de caso o denominadas "olas" constituían hechos imprevisibles y que escapaban de la debida diligencia del **CONSORCIO**.

Bajo ese contexto, no es admisible sostener que el **DEMANDANTE** tenía pleno conocimiento del incremento de casos que se iba a presentar con la llegada de la tercera ola y que debía tomar las medidas del caso, ya que ello significaría atribuirle una responsabilidad que no le es imputable, toda vez que el **CONSORCIO** no es quien generó el incremento de los contagios del Covid 19.

6.42 Por otro lado, el **CONTRATISTA** adjunto a la solicitud de ampliación de plazo presentada mediante Carta N° 002-2022/CONSORCIOASTOR/RC, la comunicación remitida por el Gerente General de la empresa Fundición Moreno SAC, en donde manifestaba que "*(…)por motivos de inventario no tuvimos producción la última semana de diciembre, además le informamos que venimos laborando en la actualidad con un 50% de personal por la pandemia del COVID-19, todo esto con la finalidad de evitar la propagación de COVID-19, en merito a R.M. 1275-2020-MINSA y Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Art. 60), asimismo en nuestra empresa Fundición Moreno SAC también se presentaron más casos positivos de COVID 19, afectando el avance de la producción.*"

6.43 En ese sentido, se puede apreciar que se ha corroborado que desde fines de diciembre de 2021 se produjo un incremento de casos lo cual desencadeno en la tercera ola del Covid 19 en el Perú; que el proveedor del **CONTRATISTA** tuvo que trabajar con el 50% de su personal durante el periodo de la tercera ola por lo cual no pudo entregar los bienes requeridos en el plazo pactado; que el incremento de casos no puede ser atribuido al **CONSORCIO** debido a que constituye un hecho extraordinario; y, que la **ENTIDAD** no ingreso a analizar las causales expuestas por el **DEMANDANTE**, limitándose a sostener que no procede la presentación de una nueva solicitud de ampliación de plazo por las mismas causales, a pesar de que no habían sido analizadas las mismas en ninguna de las solicitudes presentadas.

6.44 Por todo lo antes expuesto, el Árbitro Único considera que la solicitud de ampliación de plazo para la ejecución del Contrato N° 033-2021-SEDA-

AYACUCHO/G.G. de fecha 23 de diciembre de 2021, peticionado mediante Carta N° 002-2022/CONSORCIOASTOR/RC debe ser declarada procedente.

Segundo Punto Controvertido
"Determinar si, subordinamente al primer punto controvertido, corresponde que el Tribunal Arbitral declare como justificado el retraso del CONSORCIO ASTOR en la ejecución del contrato 033-2021-SEDA-AYACUHCO/G.G. de fecha 23 de diciembre de 2021."

Posición del CONTRATISTA:

6.45 El **CONTRATISTA** señala que en caso el Tribunal Arbitral no acogiera la primera pretensión principal, se considere como justificado el retraso incurrido por el **CONSORCIO** para la entrega de los bienes y, consecuentemente no corresponde aplicar la penalidad por mora.

6.46 En tal sentido, funda la pretensión subordinada en el artículo 162 numeral 162.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la cual señala: "*El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese último caso, la calificación del retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo*".

6.47 Para el presente caso, de acuerdo a las bases integradas del procedimiento de selección, se fijó como plazo para la entrega de los bienes 25 días calendarios en una entrega única. De ello, es evidente que no se exigió que los postores cuenten con el stock de los bienes y que, una vez firmado el contrato, obligaba al postor ganador a fabricarlos, ya que no son accesorios comerciales.

6.48 En el procedimiento de selección, el **CONSORCIO** oferto los accesorios en la Marca FUMOSAC; por lo que, una vez suscrito el contrato, nos pusimos en contacto con la empresa a efectos de que empiece por producirse los bienes solicitados por la **ENTIDAD**. Sin embargo, grande fue nuestra sorpresa al recibir la respuesta de la empresa quienes nos manifestaron que no sería posible cumplir con la entrega de los bienes dentro de la fecha pactada, ello debido a las restricciones emitidas por el Gobierno Central (a causa de la tercera ola del COVID 19) y a la alta presencia de casos positivos de COVID 19 en sus trabajadores, lo que retraso la producción prevista.

6.49 Como se manifestó en el numeral 17 de la demanda, la tercera ola del COVID 19 y la falta de producción de los bienes por la empresa FUMOSAC, constituyen hechos ajenos a la voluntad del **CONSORCIO** que impidieron que podamos cumplir con la entrega de los bienes dentro del plazo

establecido. Dichos eventos se encuentran debidamente acreditados por nuestra parte.

6.50 Sobre ello, el OSCE, mediante Opinión N° 012-2021/DTN, ha señalado: "… *la forma idónea de justificar el retraso es mediante la solicitud de ampliación de plazo presentada en la oportunidad señalada en la normativa; en adición a ello, la norma establece que el contratista puede solicitar a la Entidad no aplicar la penalidad por mora al haberse configurado un retraso justificado bajo los términos del numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento, para lo cual deberá acreditar y sustentar de manera objetiva que el retraso en la ejecución del contrato obedece a una situación que no resulta imputable a él; así, a partir de la información proporcionada a la Entidad, ésta evalúa y, consecuentemente,* ***determina*** *si dicho retraso califica como uno "justificado", a efectos de no aplicar la penalidad por mora. Cabe resaltar que, en este segundo supuesto, solamente se considera justificado el retraso cuando la Entidad así lo ha decidido*".

6.51 Para el caso objeto de análisis, la demora en la entrega de los bienes descritos en la cláusula tercera del Contrato, no son atribuibles al **CONSORCIO**, ya que el **DEMANDANTE** fue diligente al realizar el pedido de los bienes a la empresa FUMOSAC de manera anticipada, no pudiendo prever que, a raíz de la tercera ola, se vean limitados en la producción ello debido a las restricciones del Gobierno Central y contagios masivos de sus trabajadores con el Covid. En tal sentido, al no ser responsables por la demora en la entrega de los bienes, corresponde que el Árbitro Único considere como justificado, el retraso incurrido por nuestra parte en el cumplimiento de nuestras obligaciones y, por ende, ordene que no corresponde aplicarse la penalidad por mora.

Posición de la ENTIDAD:

6.52 La **ENTIDAD** ha manifestado que respecto a esta pretensión subordinada a la primera pretensión principal, debe ser rechazada en todos sus extremos, toda vez que a la fecha ya no está vigente el contrato suscrito y el **CONSORCIO** en su oportunidad ha solicitado justificar el retraso y a estas alturas pretender invocar el artículo 162 numeral 162.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sería ilegal y estaría vulnerando los principios de legalidad, trato justo, igualdad y oportunidad que consagra la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

6.53 Con relación al punto 21 de la demanda, el **DEMANDANTE** tenía pleno conocimiento y es más dentro su propuesta a ofertado que su representada estaba en la capacidad de entregar el bien en el plazo de 25 días calendario, y frente a los demás postores sacó ventaja precisamente porque asumía que podía cumplir con la entrega de los bienes en el plazo más breve. Por otro lado, se debe tener presente al momento de evaluar que **SEDA AYACUCHO** es una empresa prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado y los bienes que adquiere es de manera prioritaria para garantizar el servicio de agua potable, que en

estos tiempos de emergencia sanitaria a consecuencia del COVID 19 es elemental e imprescindible. Es más, el **CONSORCIO** al suscribir el contrato se ha acogido a las obligaciones y responsabilidades que ello requería. Por lo que, la Emergencia Sanitaria a consecuencia del COVID 19, que venimos viviendo desde el 15 de marzo de 2022, no es un evento posterior a la suscripción del Contrato N° 033-2021-SEDA AYACUCHO/GG.

Decisión del ÁRBITRO ÚNICO:

6.54 Nuestra legislación permite que las pretensiones se puedan acumular. En razón de ello, la acumulación puede ser subordinada, alternativa o accesoria. Es subordinada cuando la pretensión queda sujeta a la eventualidad de que la propuesta principal sea desestimada. Por ejemplo, si se plantea como pretensión principal que se ordene el archivo de un procedimiento sancionador por no existir infracción, se puede acumular una pretensión subordinada para que, en caso no se ampare la primera, se reduzca la multa impuesta. Es alternativa cuando el demandado elige cuál de las pretensiones va a cumplir, al considerar que se trata de pretensiones como idéntica causa de pedir, pero distinto pedido. Si el demandado no elige la pretensión alternativa a ejecutarse, lo hará el demandante. Es accesoria cuando hay varias pretensiones y, al declararse fundada la principal, se amparan también las demás. En ese sentido, la fundabilidad de la pretensión principal constituye causa necesaria y suficiente para el amparo de la pretensión accesoria.

6.55 En el presente caso, el **CONSORCIO** ha formulada una pretensión subordinada; sin embargo, la primera pretensión principal ha sido amparada, motivo por el cual carece de objeto pronunciarse respecto del segundo punto controvertido, la cual contemplaba una pretensión subordinada a la primera pretensión principal.

Tercer Punto Controvertido

"Determinar, si corresponde que el que el Tribunal Arbitral ordene al SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A. – SEDA AYACUCHO devolver la suma de S/ 24.956.71 (Veinticuatro mil novecientos cincuenta y seis con 71/100 soles) a favor del CONSORCIO ASTOR, monto deducido en su pago final, por concepto de penalidad por mora."

Posición del CONTRATISTA:

6.56 El **CONSORCIO** señala que habiéndose demostrado que existen causales que justificaron ampliarse el plazo contractual y/o se acreditó de manera objetiva que los retrasos incurridos en la entrega de los bienes no fueron atribuibles al **DEMANDANTE**, corresponde que el Árbitro Único ordene a la **ENTIDAD** cumpla con devolver al **CONTRATISTA** el monto retenido por concepto de penalidad, el cual asciende a la suma de S/. 24,956.71 (Veinticuatro mil novecientos cincuenta y seis con 71/100 soles).

6.57 Conforme se describe en el numeral 165.5 del art. 165 del Reglamento, no corresponde aplicarse la penalidad por mora, cuando se apruebe ampliaciones de plazo a su favor o cuando se acredite objetivamente que el retraso en el cumplimiento del contrato no le sea atribuible al **CONTRATISTA**.

6.58 Para el caso concreto, según el documento presentados oportunamente a la **ENTIDAD** en nuestra solicitud de ampliación de plazo (Carta N° 001-2022-FUMOSAC), se demuestra objetivamente que la demora en la entrega oportuna de los bienes fue por eventos no imputables a nuestra parte, siendo ello el resultado de eventos extraordinarios, imprevisibles e irresistibles que impidieron que el **CONSORCIO** cumpla con sus obligaciones dentro de los 25 días pactados en el contrato.

Posición de la ENTIDAD:

6.59 La **ENTIDAD** indica que en atención lo señalado por el **DEMANDANTE** en el punto 26 de su demanda que no se ha otorgado la ampliación de plazo, toda vez que el **CONSORCIO** conforme a lo señalado en la contestación, el **CONTRATISTA** en su solicitud de ampliación de plazo no ha sustentado conforme al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado artículo 198 numeral 198.1, el cual señala que el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo, mediante Resolución de Gerencia N° 012-2022-SEDA AYACUCHO/GG.

6.60 Agrega que respecto al punto 27 de la demanda, la aplicación de la penalidad por mora fue en estricta aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; y conforme a lo señalado en el Contrato N° 033-2021-SEDA AYACUCHO/GG; y la ampliación de plazo fue declarado improcedente conforme a lo argumentado en la contestación de la demanda, y el **CONSORCIO** en su oportunidad no ha acreditado objetivamente el retraso en el cumplimiento del contrato y ahora cuando el contrato suscrito ya no está vigente quiere sorprender invocando el artículo 165 numeral 165.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Decisión del ÁRBITRO ÚNICO:

6.61 Al momento de resolver el analizar el primer punto controvertido, se determinó que se había podido corroborar que desde finales de diciembre de 2021 se produjo un incremento de casos lo cual desencadeno en la tercera ola del Covid 19 en el Perú; que el proveedor del **CONTRATISTA** tuvo que trabajar con el 50% de su personal durante el periodo de la tercera ola por lo cual no pudo entregar los bienes requeridos en el plazo pactado; que el incremento de casos no puede ser atribuido al **CONSORCIO** debido a que constituye un hecho extraordinario; y, que la **ENTIDAD** no ingreso a analizar las causales expuestas por el **DEMANDANTE**, limitándose a sostener que no procede la presentación de una nueva solicitud de ampliación de plazo por las mismas causales, a pesar de que no habían sido analizadas las mismas en ninguna de las solicitudes presentadas.

Por ello, el Árbitro Único concluyo que la solicitud de ampliación de plazo para la ejecución del Contrato N° 033-2021-SEDA-AYACUCHO/G.G. de fecha 23 de diciembre de 2021, peticionado mediante Carta N° 002-2022/CONSORCIOASTOR/RC debía ser declarada procedente.

6.62 En atención al hecho de que la ampliación de plazo solicitada por el **CONTRATISTA** ha sido amparada en el curso del presente proceso arbitral, corresponde dejar sin efecto la penalidad por mora impuesta por la **ENTIDAD** y por ende, ordenar que se devuelva la suma de S/ 24.956.71 (Veinticuatro mil novecientos cincuenta y seis con 71/100 soles) a favor del **CONSORCIO**, el cual había sido deducido en su pago final.

Cuarto Punto Controvertido

"Determinar si corresponde que el Tribunal Arbitral ordene a la SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A. – SEDA AYACUCHO realizar el pago de todos los gastos arbitrales, costas y costos y demás gastos que se generen del presente proceso."

Posición del CONTRATISTA:

6.63 El **CONTRATISTA** señala que teniendo en cuenta que la decisión adoptada por **SEDA AYACUCHO** transgrede el marco normativo de contrataciones del Estado, en defensa de los derechos e intereses de nuestra representada, mediante Carta s/n presentada el 21 de abril de 2021, solicitamos el impulso del procedimiento conciliatorio ante el Centro de Conciliación Ayacucho Conciliador; de conformidad con lo establecido por el artículo 45 del T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

6.64 Llevadas a cabo las sesiones de audiencia del procedimiento conciliatorio, no habiendo arribado las partes a un acuerdo satisfactorio, mediante Acta de Conciliación N° 020-2022, de fecha 25 de febrero de 2022, se formalizó el no acuerdo de las partes contractuales.

6.65 El **CONSORCIO** cumplió con realizar la entrega del total de los bienes descritos en el contrato, los cuales, en enero de 2022, debido a la coyuntura política y alza constante del dólar, incrementaron sus precios; sin embargo, nuestra parte nunca solicitó el incremento de los precios, por lo que no se tenía la expectativa de ganancia proyectada al momento de participar en el procedimiento de selección.

6.66 A pesar de que nuestra parte mantuvo el precio pactado, la **ENTIDAD** sin evaluar adecuadamente los documentos presentados por nuestra parte y las circunstancias en enero de 2022, deniega sin mayor fundamento una solicitud de ampliación de plazo el cual se encontraba debidamente justificada, obligando a que el **CONSORCIO** active los mecanismos señalados en la norma a efectos de que vuestro tribunal resuelva la presente controversia, continuando el perjuicio generado a nuestra parte, ya que debemos afrontar los gastos que se irroguen.

6.67 Ante ello, considerando la negativa de la **ENTIDAD** de solucionar la controversia en la conciliación, corresponde que se condene a la **DEMANDADA** el pago de las costas y costos del presente proceso arbitral.

Posición de la ENTIDAD:

6.68 La **ENTIDAD** sostiene que la improcedencia de la solicitud de ampliación de plazo fue responsabilidad del **DEMANDANTE**, quien no cuantificó el número de días que requerían como ampliación de plazo, como exige el numeral 198.1 del artículo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que en el presente caso, el **CONSORCIO** deberá asumir los costos y costas del arbitraje.

Decisión del ÁRBITRO ÚNICO:

6.69 El artículo 73 de la Ley de Arbitraje establece que:

> *"1. El Tribunal Arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso".*

6.70 En el presente proceso arbitral, la primera y la segunda pretensión principal solicitada por el **CONTRATISTA** ha sido amparada, por lo cual a consideración del Árbitro Único corresponde que la **ENTIDAD** como parte vencida asuma la totalidad de los costos y costas, que hubiesen sido acreditados en el curso del arbitraje.

6.71 En tal sentido, el Árbitro Único ha procedido a revisar cada uno de los escritos y los medios probatorios aportados por las partes, pudiéndose advertir que ninguna de ellas, ha cumplido con presentar un detalle de los costos y costas que han peticionado ni tampoco han presentado los documentos que sustenten los mismos.

6.72 En consecuencia, el Árbitro Único únicamente podrá pronunciarse respecto de las costas y costos que se encuentran acreditados en el expediente arbitral.

6.73 En atención a ello, y al hecho de que se ha amparado las pretensiones antes indicadas, el Árbitro Único considera que la **ENTIDAD** debe reembolsar al **CONSORCIO** únicamente los pagos efectuados por el **CONTRATISTA** correspondientes a los honorarios arbitrales y a los gastos de la Secretaria Arbitral que ha cancelado en el curso del presente proceso arbitral.

VII. LAUDO.

Sobre la base de la voluntad de las partes, de los argumentos esgrimidos, la valoración de las pruebas presentadas y actuadas, así como de las consideraciones antes expuestas, el Árbitro Único lauda en Derecho resolviendo:

PRIMERO: Declarar **FUNDADA** la primera pretensión del **CONTRATISTA**, y en consecuencia, declarar procedente la solicitud de ampliación de plazo para la ejecución del Contrato N° 033-2021-SEDA-AYACUCHO/G.G. de fecha 23 de diciembre de 2021, peticionado mediante Carta N° 002-2022/CONSORCIOASTOR/RC, de conformidad a los argumentos expuestos en la parte considerativa del presente laudo.

SEGUNDO: Declarar que **CARECE DE OBJETO PRONUNCIARSE** respecto de la pretensión subordinada a la primera pretensión principal formulada por el **CONTRATISTA**, debido a que la primera pretensión principal se declaró fundada, de conformidad a los argumentos expuestos en la parte considerativa del presente laudo.

TERCERO: Declarar **FUNDADA** la segunda pretensión principal del **CONTRATISTA**, y en consecuencia, corresponde ordenar a la **ENTIDAD** que devuelva la suma de S/ 24.956.71 (Veinticuatro Mil Novecientos Cincuenta y Seis con 71/100 soles) a favor del **CONSORCIO**, monto que fuera deducido del pago final por concepto de penalidad por mora, de conformidad a los argumentos expuestos en la parte considerativa del presente laudo.

CUARTO: En cuanto a los costos y costas que se han originado en el presente arbitraje, el Árbitro Único **DISPONE** que la **ENTIDAD** le reembolse al **CONTRATISTA** los pagos efectuados correspondientes a los honorarios arbitrales y a los gastos de la Secretaria Arbitral que ha cancelado en el curso del presente proceso arbitral, de conformidad a los argumentos expuestos en la parte considerativa del presente laudo.

José Antonio León Rodríguez
Árbitro Único

Raida Yovana Flores Cayllahui
Secretaria Arbitral